第 9 章

債権の担保

第1節　物的担保
第2節　人的担保
第3節　その他、担保的性質を有するもの

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　物的担保

この節で学ぶこと

取引によって生じた債権は、順当に決済（弁済）されてはじめて活動の成果が実現する。ビジネスパーソンは日常的に自社の債権を回収する手立てを心がける一方で、万一債権回収に支障が生じそうな事態が生じた場合には、確実な債権回収のために種々の法的手段を講じる必要がある。このような債権確保手段が債権の担保である。

この節では、抵当権・根抵当権・譲渡担保に関し3級公式テキストでは説明していない重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

物的担保の効力（優先弁済的効力・追及効）と性質（附従性・随伴性・不可分性・物上代位性）、留置権・先取特権・質権・抵当権、譲渡担保

3級の復習 【1】～【5】

担保物権とは、債務者がその債務を履行しない場合に、債務者または第三者の特定の財産から他の債権者に先んじて債権の回収を図ることのできる権利である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【1】担保物権の性質（通有性）と効力

性質	附従性	被担保債権が成立してはじめて担保物権も成立し、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質
	随伴性	被担保債権が他人に移転した場合に担保物権もこれに伴って移転するという性質
	不可分性	担保物権を有する者は、被担保債権全部の弁済を受けるまで、目的物の全部の上にその権利を行使することができるという性質
	物上代位性	担保物権を有する者は、担保目的物の売却、賃貸および滅失等により債務者が受ける売買代金、賃料および保険金等の金銭等に対しても、権利を行使することができるという性質
効力	優先弁済的効力	弁済がないときは、担保の目的物を換価し、その代金から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる効力 物上代位性は優先弁済的効力が認められる担保物権にのみ認められる
	留置的効力	被担保債権の弁済を受けるまで、担保の目的物を債権者の手元に留め置く効力

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

		法定担保物権		約定担保物権	
		留置権	先取特権	質権	抵当権
性質	附従性	○	○	○	○
	随伴性	○	○	○	○
	不可分性	○	○	○	○
	物上代位性	×	○	○	○
効力	優先弁済的効力	×	○	○	○
	留置的効力	○	×	○	×

【2】留置権（民法上の留置権）

意義	他人の物の占有者がその物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利
要件	①留置権者が他人の物を占有していること（民法295条1項本文） ②その物に関して生じた債権を有すること（債権と目的物との間の牽連関係、民法295条1項本文） ③被担保債権が弁済期にあること（民法295条1項但書） ④占有が不法行為によって始まったものでないこと（民法295条2項）
効力等	①留置権者は被担保債権の弁済を受けるまで、目的物を留置することができる（留置的効力）。 ②留置権者は留置物を占有している限り、留置物が第三者に譲渡されても留置権は消滅せず、譲受人に対抗することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（民事留置権と商事留置権）

	民事留置権 （民法295条）	商事留置権 （商法521条）
被担保債権と留置物との関連性	債権（修理代金）と留置物（目的物）との間に関連性（牽連関係）が必要である。	民事留置権におけるような債権と留置する物との間の牽連関係は不要である。
留置物	債務者所有の物に限られない。	債務者所有の物に限られる。
効力	破産法等の倒産処理手続において、別除権は認められていない。	破産法・民事再生法上、別除権が認められる（破産法66条1項、民事再生法53条1項）。会社更生法上、更生担保権として扱われる（会社更生法2条10項）。

【3】先取特権

意義	法律で定める特別な債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることができる担保物権
種類	①一般先取特権：債務者の総財産の上に成立する先取特権 ②動産先取特権：債務者の特定の動産の上にのみ成立する先取特権 ③不動産先取特権：債務者の特定の不動産の上にのみ成立する先取特権

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【4】質権

意義	債権の担保として質権設定者（債務者・第三者）から受け取った目的物を質権者（債権者）が占有し、その物から他の債権者に優先的に弁済を受けることができる担保物権		
種類	動産質	不動産質	権利質
成立要件	設定契約＋引渡し（要物契約）		設定契約 ※証券の交付（民法520条の7・520条の2）等が必要な場合あり
対象	譲渡可能な動産	土地・建物	債権その他の権利
対抗要件	占有の継続（民法352条）	登記（民法177条）	債務者への通知または債務者の承諾（民法364条・467条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【5】抵当権

意義		債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、債権者が他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権。
成立要件		抵当権者（債権者）と抵当権設定者との間の設定契約（諾成契約）。 ・抵当権設定者：債務者、第三者（物上保証人） ・目的物：不動産、地上権、永小作権（民法369条）
対抗要件		登記（民法177条）
抵当権の効力の及ぶ範囲		抵当権の目的となっている不動産（土地、建物）そのものだけではなく、抵当権設定の時点で抵当不動産上に存し、その経済的な効用を助けるために継続してその不動産に備えられたものにも及ぶ（民法370条）。
抵当権の被担保債権の範囲		抵当権の被担保債権には、元本のほか、利息、損害賠償金まで含まれる。ただし、利息や損害賠償金については、後順位抵当権者がいる場合は、満期が到来した最後の2年分についてのみ優先弁済権を主張できる（民法375条）。
物上代位	意義	抵当権者は、抵当目的物の売却、賃貸および滅失等により債務者が受ける売買代金、賃料および保険金等の金銭その他の物に対しても、抵当権を行使することができる（民法372条・304条）。
	行使要件	払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない（民法304条1項但書）。これは、弁済済みの第三債務者が、さらに抵当権者に対しても弁済しなければならなくなる危険を防止するためである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　抵当権〔mortgage；hypothec〕

(1) 抵当権の実行

ア)抵当権の優先弁済的効力

抵当権の本質的な効力として、優先弁済的効力がある。抵当権者は、弁済期が到来しても債務者が弁済しないとき、その目的物を強制的に売却し、その代金から優先的に弁済を受けることができる。他の担保権者等よりも先に登記がなされた対抗力のある抵当権は、他の担保権者等の申立てで抵当権の認定された不動産等について競売が開始しても、その順位に応じて優先的に配当を受けることができる(民事執行法87条1項4号)。設定者が破産した場合でも、対抗力のある抵当権者は、破産手続による制限を受けずに権利を行使することができる別除権者(べつじょけんしゃ)として保護される(破産法2条9項・65条)。

抵当権と国税・公課金等の租税債権との関係については、抵当権が国税の法定納付期限等の以前に設定登記されたものであれば、国税に優先する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　更地（さらち）に抵当権を設定する場合の注意点

建物等の建っている土地（底地）に比べ、建物等の工作物が建っていない土地である更地は、一般に処分、換価がしやすく、担保としての価値が高いとされている。一方で、更地は、抵当権等の担保権の設定後に、建物等が建築されたり、第三者にそのまま譲渡・賃貸されるおそれがある。

そこで、更地に抵当権を設定する場合には、抵当権者に無断で上記の行為をすることの禁止、目的物件に建物の建築等するときは抵当権者に通知し、増担保、代わり担保を提供すること、これらに違反すると期限の利益を喪失すること等が設定契約に定められることが多い。

実際に、更地に抵当権が設定された後に抵当権設定者が当該土地上に建物を建築した場合、抵当権の効力は建物には及ばないが、当該土地の抵当権者は、土地と建物を同時に競売することができる。ただし、抵当権者が優先弁済を受けられるのは、抵当権が設定されている土地の競売代金に限られる（民法389条）。建物の競売代金については、抵当権者であっても優先権がないため、他の一般債権者とともに債権額に応じて按分した額の配当を受けることになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

したがって、抵当権者は、抵当権設定者が抵当目的物である更地に建物を建築する場合には、建物にも抵当権を設定することを条件とすることが望ましいといえる。

イ）抵当権の実行としての不動産競売手続

抵当権を実行するための競売申立てをするには、抵当権が現に存在し、その抵当権によって担保される被担保債権が履行遅滞に陥っていることが必要である。そして、申立書（民事執行規則1条・170条）と、所定の場合には担保権の存在を証明する文書または電磁的記録（民事執行法181条1項）を管轄の地方裁判所に提出し、申立てを行う（民事執行法188条・44条・2条）。

申立てが法定の要件を満たしている場合には、裁判所は競売の開始決定をする。この開始決定では債権者のために不動産を差し押さえる旨の宣言がなされ、法務局に依頼して差押えの登記がなされる。

競売の開始決定がなされると、担保目的物の調査が行われ、裁判所は最低売却価格を決定する。その後、裁判所は売却の手続に入り、一般に最高価格で買受けを申し出

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

た者に売却の許可決定が下される。買受人は、代金を納付し、担保目的物（競売目的物）の所有権を取得する。

　抵当権者や他の債権者は、売却代金から配当を受けることにより、債権を回収する。

（不動産競売手続の流れ）

競売開始決定



不動産所在地の地方裁判所による競売開始決定
差押えの嘱託登記

売却手続



執行官による現況調査評価人による不動産評価
最低売却価格の決定
不動産売却方法等の公告買受けの申出
買受人の保証金納付
売却許可決定
代金納付・配当等
期限内代金納付
所有権取得
配当手続

売却後の手続

裁判所による、売却により消滅した権利や差押登記等の抹消登記
買受人への所有権移転登記

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）担保不動産収益執行手続

担保不動産収益執行とは、抵当権などの担保権が設定された不動産から生じる収益（賃料など）を被担保債権の弁済に充てる方法によってなされる不動産担保権の実行をいう（民事執行法180条2号）。

担保不動産収益執行手続には、民事執行法上の強制管理の規定が準用されている（民事執行法188条・93条以下）。強制管理の制度は、不動産の差押債権者のために、当該不動産の管理人が選任され、その管理人が当該不動産の管理、収益の取得、収益の換価などを行い、そこで得られた金銭を配当する手続である。

（3）抵当権と抵当目的物の利用権

抵当権は、設定目的物の交換価値（金銭的に評価した価値）を把握する権利であり、原則として、その設定によって目的物の利用関係は影響を受けない。しかし、一度抵当権が実行されると、買受人（かいうけにん）への所有権移転とともに抵当権に対抗できない利用関係はすべて消滅するため、不動産の利用関係は著しく不安定なものとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、民法は、抵当目的物に設定された抵当権と利用権の関係を調整するために、法定地上権（民法388条）、抵当権登記後の賃借権についての抵当権者の同意（民法387条1項）などのほか、後述する抵当権の消滅請求（民法379条）等の制度を設けている。

ア）法定地上権〔statutory superficies〕

同一人が土地と建物を所有しており、その一方（例えば建物）に抵当権を設定し、その後抵当権が実行され第三者が買い受けるなど所定の要件を充たす場合、土地所有者と建物所有者が異なることとなるが、建物所有者には土地の利用権が認められない。そこで、建物所有者を保護するため、建物所有者（建物が競売された場合はその買受人）には、土地上に法律上当然に地上権が認められる（民法388条）。これを法定地上権という。

法定地上権の成立要件は、次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 抵当権設定当時土地の上に建物が存在していたこと
② 抵当権設定当時同一人がその土地と建物を所有していたこと
③ 両者の一方または双方に抵当権が設定され、競売の結果別々の者がそれぞれを所有するに至ったこと

法定地上権の取得を第三者に対抗するには、建物の登記または地上権の登記が必要である。

法定地上権が成立する範囲は、建物の敷地のみならず、建物の利用に必要な土地を含む。また、存続期間や地代に関し当事者が決定できないときは裁判所がそれを決定する（民法268条2項・388条）。

なお、法定地上権は、強制競売（民事執行法81条）・国税徴収法による公売（国税徴収法127条）があった場合にも成立する。

イ）抵当権登記後の賃借権についての抵当権者の同意

抵当権の登記がなされた後に設定された利用権は、抵当権の実行により消滅するのが原則であるが、抵当権の登記後の建物の賃借人など一定の者は、その保護を図る必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、抵当権の登記後の賃借権を保護するため、抵当権登記後の賃借権についての抵当権者の同意という制度が設けられている（民法387条1項）。これは、抵当権登記後に抵当権の設定された不動産を賃借する者が、賃借権の登記と、賃借権登記の前に登記を経由した全抵当権者の同意を得てその旨の登記をした場合には、当該賃借権を抵当権者に対抗することができるとする制度である。

ウ）明渡猶予（あけわたしゆうよ）〔suspension of delivery by users of mortgaged buildings〕

建物に抵当権が設定されその登記がなされた後、当該建物が賃貸された場合、賃借人は原則として自己の賃借権を抵当権者に対抗することができない。そのため、抵当権が実行され、第三者が当該建物を競売により買い受けると、賃借人は建物を明け渡さなければならない。しかし、貸借人が自宅として居住している場合など、早急に明渡しを迫られることは、賃借人に酷であると考えられる場合も少なくない。

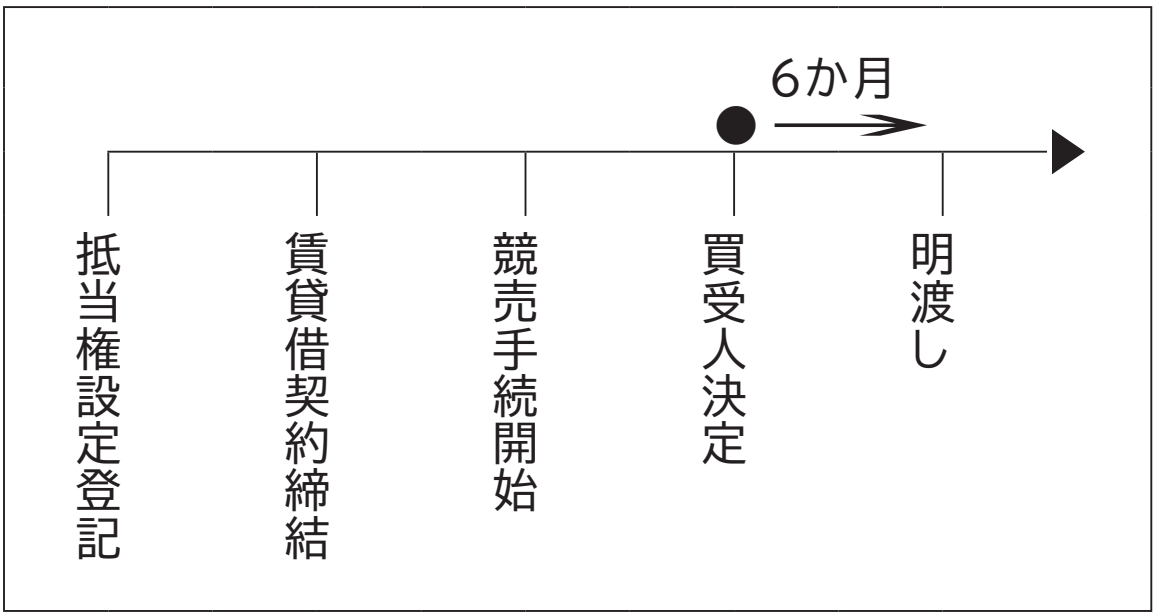
© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、抵当権に対抗できない建物賃借権の賃借人が、競売手続開始前から使用または収益を行っている場合などには、その建物の競売における買受人の買受けの時点から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に明け渡さなくてもよいとされている（民法395条1項）。もっとも、その間、賃借人は建物使用の対価を買受人に対して支払わなければならず、買受人から相当の期間を定めて1か月分以上の対価の支払いを催告されたにもかかわらず、相当の期間内にその支払いをしなかった場合には、買受けの時点から6か月を経過していなくても明け渡さなければならない（民法395条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【明渡猶予制度】

競売が開始されると、買受人決定後6か月間明渡しが猶予される。



（4）抵当不動産の第三取得者の地位

抵当権が設定されている不動産（抵当不動産）は第三者への売買等により処分することができるが、後に抵当権が実行されると、当該第三者は抵当不動産につき取得した権利（所有権など）を失うことになる。このような第三取得者の地位にかかわる制度として、代価弁済と抵当権消滅請求がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア)代価弁済〔payment of mortgage proceeds〕

代価弁済とは、抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその不動産の代価(売買代金など)を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅するという制度である(民法378条)。

代価弁済は、後に述べる抵当権消滅請求と同様に抵当権を消滅させる効果があるが、抵当権消滅請求とは異なり、抵当権者の請求により認められるもので、抵当権者に主導権がある。

イ)抵当権消滅請求〔claim for extinguishment of mortgage〕

抵当権消滅請求とは、抵当不動産の第三取得者が抵当権者に対して、抵当権の消滅を請求する制度である(民法379条以下)。

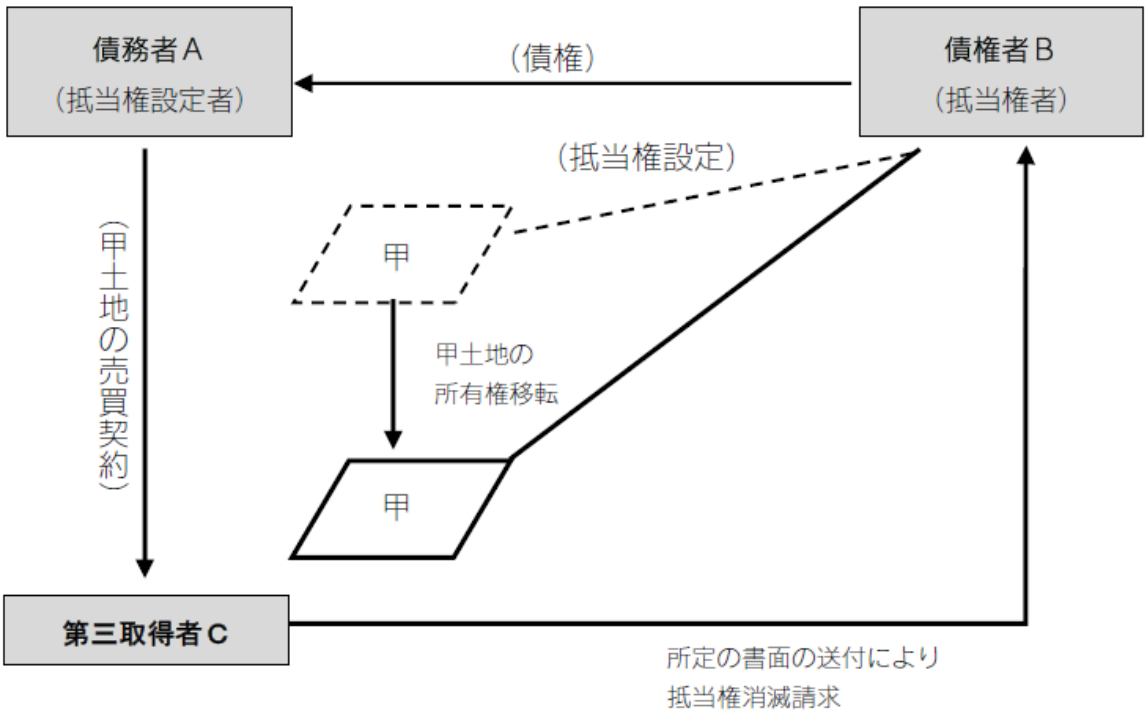
抵当権の設定された不動産の所有権を取得した者が、抵当権者等の登記をした債権者に対して所定の書面等を送付することによって抵当権消滅請求を行うと、抵当権者は当該書面到達の日から2か月以内に競売申立

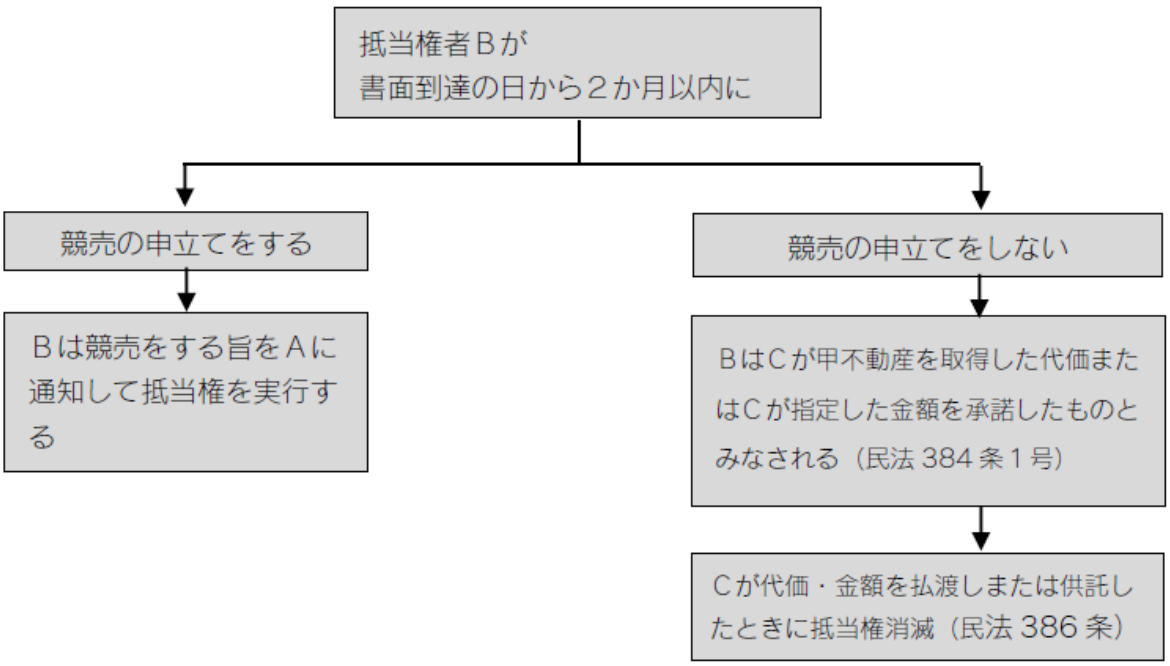
© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

てをしなければ、この消滅請求を承諾したものとみなされ、第三取得者等の申し出た代価の支払いをもって満足しなければならない。

例えば、債務者Aは、Bに対して負担する債務を担保するため、自己所有の甲土地に抵当権を設定し登記を経た後、甲土地をCに譲渡した。この場合、甲土地の第三取得者であるCは、登記を経た抵当権者Bに民法383条所定の書面を送付して抵当権消滅請求をすることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD





© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《抵当不動産の第三取得者の地位》

制度名	誰が請求するか	誰に対して行使するか
代価弁済	抵当権者	抵当不動産につき、①所有権、②地上権を買い受けた者
抵当権消滅請求	抵当不動産の第三取得者	抵当権者

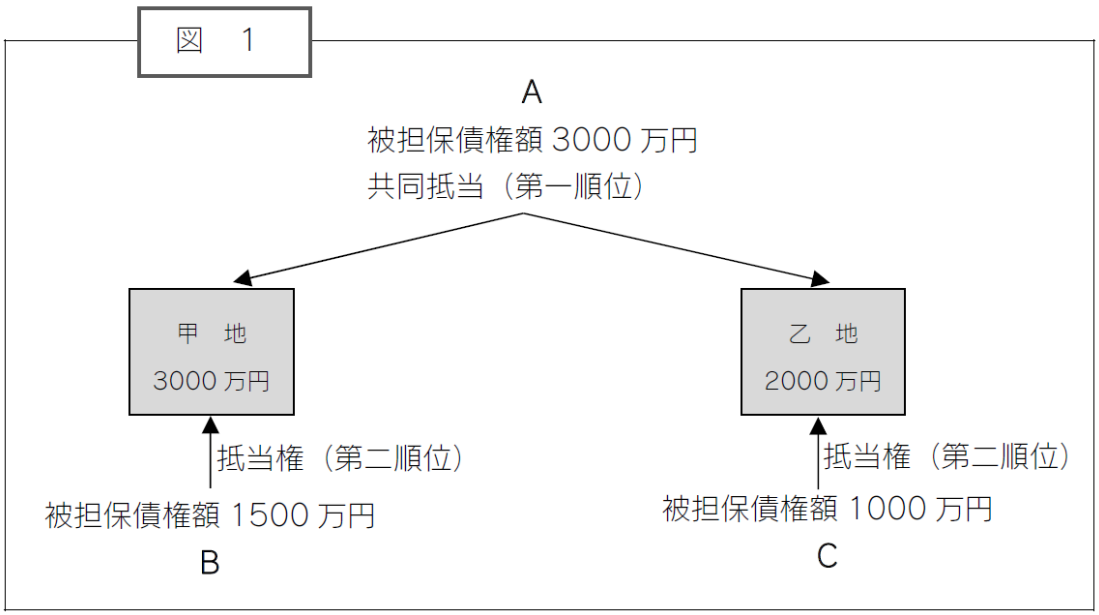
（5）抵当権の処分

抵当権により担保されている債権が譲渡されると、譲渡後の債権も従前の抵当権により担保される（抵当権の随伴性）が、抵当権自体を被担保債権から切り離して処分することもできる。転抵当や抵当権の譲渡・放棄および抵当権の順位の譲渡・放棄（民法376条）、抵当権の順位の変更（民法374条）はこれに当たる。もっとも、これらの処分は金融機関を除くとほとんど活用されていない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

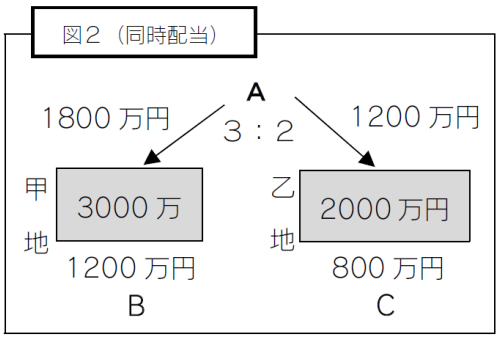
（6）共同抵当〔joint mortgage〕

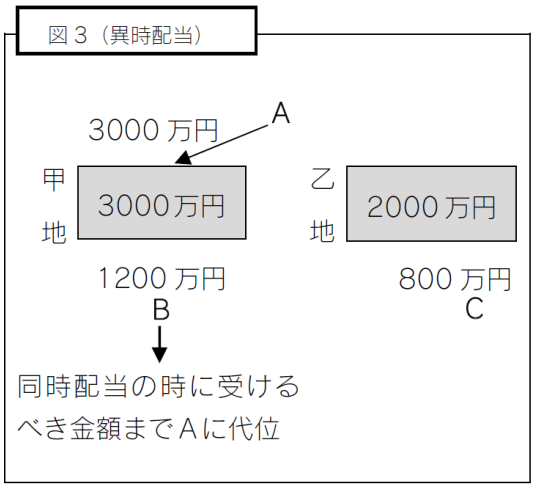
ある特定の債権を担保するために、複数の不動産の上に1つの抵当権を設定することが可能であり、これを共同抵当と呼ぶ。（図1）



民法は、①共同抵当権者は、抵当不動産の全部について同時に競売を申し立て、その競売代金について同時に配当を受ける場合（同時配当）と、②共同抵当権者が、抵当不動産の1つについて競売を申し立てて配当を受け、被担保債権額に不足する部分があるときに、続けて他の抵当不動産について競売を申し立てて配当を受ける場合（異時配当）の2つの場合について規定している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD





同時配当の場合には、各不動産の価額に応じ、按分（あんぶん）して債権の負担が分けられる（民法392条1項、図2）。

異時配当の場合、後順位抵当権者は、共同抵当権者が同時配当の場合に受けたであろう金額に達するまで、共同抵当権者が他の不動産について有した抵当権に代位することができる（民法392条2項、図3）。なお、この代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる（民法393条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）後順位抵当権者が、共同抵当権者が他の不動産について有した抵当権に代位するとはどういうことか。

A）図3を例にすると、共同抵当権者Aは甲地の競売価格である3000万円から全額の弁済を受けているので、後順位抵当権者Bは甲地から全く弁済を受けられないことになる。しかし、これではAが同時配当を受けた場合に、Bは甲地から1200万円全額の弁済を受けられたこととの不均衡が生じ、甲地から弁済を受けられることを期待したBの利益を損なうことになる。そこで、Bは、同時配当の場合に、Aが乙地から弁済を受けられた額である1200万円（図2参照）について、Aに代わって乙地から弁済を受けることができる。これが、共同抵当権者が他の不動産について有した抵当権に、後順位抵当権者が代位するということである。ただし、BはAに代位することを公示するために、乙地上に設定されたAの抵当権の登記に代位の付記登記をする必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　根抵当権〔revolving mortgage〕

(1) 根抵当権とは

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、設定契約で定める極度額の範囲内で担保する抵当権である。極度額とは、根抵当権によって担保される債権の上限額のことである。例えば、銀行と取引先との継続的な融資契約や商人間の継続的な商品供給契約など、ある一定の範囲内の取引から発生する不特定の債権を担保するために、根抵当権は設定される（民法398条の2）。これは、継続的な取引においては債権額の増減が必須であり、極度額という上限を設けたうえで、一定期間の分をまとめて精算し、担保するのが便宜であることから設けられた制度である。

なお、根抵当権に対して、根抵当権ではない抵当権のことを普通抵当権と呼ぶことがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（抵当権と根抵当権）

	抵当権	根抵当権
利用される場合	例えば、債権者甲社が債務者乙社に対して有している1000万円の建築請負代金債権を担保するために、乙社所有の土地に抵当権を設定する場合のように、債権者が有する確定した債権を担保するために設定される。	甲乙両社が製品についての継続的取引契約に基づいて、継続的に取引を行っている場合、毎月支払期日近くになれば甲社の売掛債権は増額し、支払期日を過ぎれば弁済によって減額する。このように増減変動する一定の債権（甲社の売掛債権）を一定の限度（例えば1億円、これを「極度額」という）で担保するために設定される。
被担保債権が消滅した場合	被担保債権（1000万円）が債務者の弁済等により消滅すれば、抵当権も消滅する。	乙の弁済等により一時的に被担保債権が消滅したとしても、根抵当権自体は依然として存続し、その後新たに売掛債権が発生すれば、根抵当権によって担保される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）根抵当権の内容

根抵当権は、当事者間の設定契約の締結により成立する。設定契約では、目的物、債権者、債務者、担保される債権の範囲、担保される債権の元本・利息・損害金の極度額、確定期日が定められる。

設定契約においては、担保される債権の範囲を定める必要があるが、この範囲の定め方について、民法は、次の方法によるべきとしている。

① 債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの（民法398条の2第2項）
② 特定の原因に基づき債務者との間に継続して生じる債権（同条3項）
③ 手形上もしくは小切手上の請求権（同条3項）
④ 電子記録債権（同条3項、電子記録債権法2条1項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

根抵当権において担保される被担保債権の額は極度額によって画され、普通抵当権と異なり、極度額の範囲内であれば、元本、利息、遅延損害金のいずれについても特段の制約なく担保される（民法398条の3第1項参照）。なお、極度額を超える部分については他の債権者等に対する配当に充てられるが、他に配当を受けるべき債権者等が存在しない場合であっても、根抵当権者は極度額を超える部分については配当を受けることができない（最判昭48・10・4判時723−42）。

設定契約の内容は、登記をすることによって第三者に対抗することができる。なお、事業の拡大や組織の変更に伴い根抵当権の設定事項を変更することもあり得る。とりわけ極度額の変更は、後順位抵当権者や差押債権者などの利害（受けられる配当の金額など）にかかわるので、当事者の合意のみならず、これら利害関係人の承諾を必要とする（民法398条の5）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）元本の確定と根抵当権の実行

根抵当権は、元本の確定前は、その実行等を行うことはできず、元本が確定した段階で普通抵当権とほぼ同様の効力が認められ、その実行等を行うことができる。確定根抵当権においては、その被担保債権は、根抵当権の担保する範囲に含まれるもので、元本の確定した日の時点で存在する債権に確定する。

（4）根抵当権の消滅

根抵当権は、その元本が確定する前は、被担保債権の残高がゼロになったとしても、それだけでは消滅しない。

元本確定後は、被担保債権の弁済による消滅など、普通抵当権と同様の理由で消滅する。また、元本確定後に、その確定した被担保債権額が根抵当権の極度額を上回っている場合でも、物上保証人や目的不動産につき所有権や第三者に対抗できる賃借権等を取得した者は、その極度額に相当する金銭を払い渡し、または供託して、根抵当権の消滅請求をすることができる（民法398条の22第1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（根抵当権の元本確定事由）

表中の引用条文はすべて民法上のものである。

<table>
<tr><td rowspan="2">当事者間で元本確定期日を定めた場合</td><td>元本確定期日の到来</td><td>当事者間で定めた、根抵当権により担保される元本が確定する日が到来すること（398条の6第1項）
・元本確定期日は、これを定める日から5年以内の日としなければならない（398条の6第3項）</td></tr>
<tr><td></td><td>元本確定期日の変更
・元本確定期日は、確定前であれば当事者間の合意により変更することができる（398条の6第1項）
・変更後の元本確定期日は変更の日から5年以内の日としなければならない（398条の6第3項）
・元本確定期日の変更に、後順位抵当権者等の利害関係人の同意は不要である（398条の6第2項）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当事者間で元本確定期日を定めていなかった場合</td><td>根抵当権設定者（目的不動産の所有者）による確定請求</td><td>根抵当権設定から3年を経過した後、根抵当権設定者が根抵当権者に対して元本の確定請求をし、その請求のときから2週間を経過した時点で元本が確定する（398条の19第1項）</td></tr>
<tr><td>根抵当権者の確定請求</td><td>・根抵当権者が元本の確定請求をした時点で元本が確定する（398条の19第2項）
・根抵当権者は、いつでも元本の確定請求をすることができる</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法定の確定事由が発生したとき（398条の20）	法定の確定事由 ・根抵当権者が、抵当不動産について、競売や物上代位のための差押え等を申し立てること ・根抵当権者が、抵当不動産に対して、滞納処分による差押えを申し立てること ・根抵当権者が、抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを知ったときから2週間を経過すること ・債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けること

3　譲渡担保

(1) 譲渡担保とは

譲渡担保は、抵当権や質権など民法等に明文の規定のある物的担保と異なり、判例上認められた物的担保（非典型担保）である。

債権者は、債権担保のため債務者などから不動産や動産などの財産権を譲り受け、弁済がないときはその財産権を自ら評価して確定的に取得することにより、優先的に弁済を受けることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（譲渡担保の実務上のメリット）

① 譲渡担保権は、抵当権とは異なり、およそ譲渡可能な物であればあらゆる物に対して設定できる。特に、抵当権を設定できない各種の動産や債権などにおいて、譲渡担保権は、担保として極めて重要な役割を果たしている。

また、工場内の機械・設備に関しても、工場抵当法等の特別法によらず、譲渡担保が設定されることもある。

② 譲渡担保権は、質権と異なり、担保目的物を債権者に引き渡す必要がない。

③ 債務者からの弁済がない場合、抵当権の場合には、通常民事執行法の手続によって抵当目的物を競売し、その売却代金から弁済を受けることになるが、これは煩雑な手続と多額の費用を要する上に、目的物を十分高価で換価できるとは限らないという実状がある。これに対して、譲渡担保権の場合には、民事執行法に定められた手続によることなく弁済を受けることができるため、より迅速かつ高額の弁済を受けられることが多い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）譲渡担保と抵当権、質権の違いは何か。

A）譲渡担保と抵当権、質権との違いは、次のような点である。

①譲渡担保

譲渡可能なものであればあらゆるものを対象にでき、目的物等の占有等は債務者に留めておいたまま設定できる。目的物等の換価に裁判所の関与は不要である。

②抵当権

その対象となるものが法律上限定されているが、目的物等の占有は債務者に留めておいたまま設定できる。目的物等の換価に裁判所の関与が必要である。

③質権

譲渡可能なものであればあらゆるものを対象にできるが、目的物等の占有等は債権者に移転しなければ設定できない。目的物等の換価に裁判所の関与が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）譲渡担保の設定

譲渡担保は、債権者と目的物の所有者との間の設定契約により設定される。この譲渡担保設定契約は、物の引渡しや書面の作成等の必要がない、諾成、不要式の契約である。

譲渡担保は、目的物の引渡し等をその成立要件とするものではないので、動産、不動産については目的物を設定者の下に留保したまま設定することができる。

（3）譲渡担保の目的物

譲渡担保は、動産や不動産のほか、債権・知的財産権など譲渡可能なものであればあらゆるものに設定することができる。

なお、譲渡担保については、個々のものでなく、例えば、倉庫内の在庫製品や特定の取引先に対して有する売掛金債権など、動産や債権などの集合物（集合債権）に対して一体として譲渡担保を設定することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

具体的には、動産の集合物については、構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる（最判昭62・11・10民集41巻8号1559頁）。

また、集合債権についても、判例は、その特定性（他の債権と容易に区別できること）が充たされている限り、一体として譲渡担保の目的とすることができるとしている。

（4）譲渡担保の対抗要件

譲渡担保権の設定を第三者に対抗するための対抗要件は、通常の譲渡の場合の対抗要件と同じと考えられている。つまり、不動産については登記、動産については引渡し、債権については債務者への通知または債務者の承諾である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このうち、動産については、譲渡担保の目的物を設定者が利用しながら担保の目的物とすることが実務上の要請として強いが、この場合に対抗要件の不完全性が問題となっていた。民法178条の引渡しは、現実の引渡しのほか占有改定でもよいとされているが、占有改定の場合、他者のための占有であることを公示する手段がなく、容易に即時取得が認められ得ることから、ネームプレートの設置などで、実務上即時取得の防止が図られていた。しかし、現在は、この動産と債権の譲渡担保の対抗要件について、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」（動産・債権譲渡特例法）により、動産譲渡登記・債権譲渡登記の制度が設けられている。

（譲渡担保の対抗要件）

	民法	動産・債権譲渡特例法
不動産	不動産登記（177条）	
動産	引渡し（178条） ・占有改定でもよい	動産譲渡登記（3条）
債権	通知・承諾（467条）	債権譲渡登記（4条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

動産・債権譲渡特例法に基づく動産譲渡登記・債権譲渡登記をすることができるのは、譲渡人が法人である動産譲渡・債権譲渡に限られる（動産・債権譲渡特例法3条・4条）。

また、債権の場合は、債権譲渡の場合と同様の対抗要件（第10章第1節5(3)参照）を備えることが必要とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　動産譲渡登記、債権譲渡登記のしくみ

動産譲渡登記制度は、法人が行う動産の譲渡について、当該法人が登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることを可能とする制度である。また、債権譲渡登記制度は、法人が行う金銭債権の譲渡について、当該法人が債務者以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度である。

この制度の概要は、次の通りである。

①登記の対象

登記の対象は、法人が譲渡人である動産譲渡、債権譲渡に限定される。譲渡の目的物については、個別動産・個別債権であっても、集合動産（倉庫内の在庫商品、工場内の機械設備等）・集合債権であっても差し支えない。債権については、債務者が特定されていない将来債権の譲渡についても、債権譲渡登記が可能とされている。

②対抗要件

動産については、動産譲渡登記ファイルに記録（登記）することにより、動産の譲渡について引渡し（民法178条）があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備される（動産・債権譲渡特例法3条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、債権の譲渡については、債権譲渡登記ファイルに記録することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、確定日付のある証書による通知（民法467条）があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備される（動産・債権譲渡特例法4条1項）。そして、債権譲渡登記がされた場合において、譲渡人もしくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、または債務者が承諾をしたときは、債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、対抗要件が具備される（動産・債権譲渡特例法4条2項）。

③登記の存続期間

動産譲渡登記の存続期間は、原則として、10年以内である（動産・債権譲渡特例法7条3項）。債権譲渡登記の存続期間は、原則として、債務者が特定している場合は50年以内、そうでない場合は10年以内である（動産・債権譲渡特例法8条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④証明書の種類と交付

現在、動産譲渡登記・債権譲渡登記を取り扱う登記所（動産譲渡登記所・債権譲渡登記所）として、東京法務局が指定されている。動産譲渡登記所・債権譲渡登記所では、動産・債権を特定する事項を含む登記事項の全部を記載した「登記事項証明書」（当事者、利害関係人、譲渡人の使用人のみが交付を請求できる）と、譲渡された動産・債権を特定する事項を除いた事項を記載した「登記事項概要証明書」（誰でも交付を請求できる）を発行している（動産・債権譲渡特例法11条）。

また、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所等では、登記事項概要ファイルを備えて登記事項の概要を記録し、譲渡された動産・債権を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載した「概要記録事項証明書」（誰でも交付を請求できる）を発行している（動産・債権譲渡特例法12条・13条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）譲渡担保の実行

譲渡担保権者は、債務者が債務を弁済しない場合には、目的物を売却し、あるいは自らが取得する形で譲渡担保の実行を行うことができる。ただし、目的物の売却価格あるいはその評価額が債権額を超えて差額が生じた場合には、その差額分の金員を設定者に対して支払わなければならない（清算義務）。

また、債権を目的として譲渡担保を設定している場合には、譲渡担保権者は、当該債権の債務者（第三債務者）に対して自ら取り立てることにより譲渡担保を実行し、自己の債権の優先的な満足を図ることができる（被担保債権額を超える部分については清算が必要）。実行する際には、譲渡担保について第三債務者に対する対抗要件を備えていることが必要である。

なお、集合動産の譲渡担保においては、その構成物が日々変動することが多いため、譲渡担保実行時における目的物の換価処分価額について不確定要素が大きい。そのため、譲渡担保の実行時において目的物である動産を明確に特定できるよう、譲渡担保設定契約を締結する際に留意しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD